

刑法

No87

R5-18

(配点：3)

月 日

月 日

正当防衛に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1. 刑法第36条第1項における「権利」には、個人の生命、身体、自由のみならず、財産も含まれる。
2. 急迫不正の侵害に対する反撃行為について防衛の意思と攻撃の意思が併存する場合、正当防衛が成立するには、その主従を比較して、前者が優越する必要がある。
3. 凶器を持たない相手からの侵害行為に対抗する場合、正当防衛が成立するには、凶器を持たずに対抗する必要がある。
4. 正当防衛は、不正の侵害に対して成立するから、相手方の過失行為に対しては、正当防衛は成立し得ない。
5. 急迫不正の侵害に対して憤激又は逆上して反撃を加えた場合でも、正当防衛は成立し得る。

No.87	正当防衛	正答率
R5-18	正解 1、5（順不同）	88%

1 正しい

最判平 21.7.16 は、共有持分権等を有する被告人による増改築工事を妨害するため、被害者が「建築禁止」と記載した看板を建物に設置する行為を防止するために行われた暴行について、被害者の行為は財産権・業務・名誉に対する急迫不正の侵害であるから正当防衛により被告人の暴行罪の違法性が阻却されるとしている。したがって、判例によれば、36条1項における「権利」には、個人の生命、身体、自由のみならず、財産も含まれる。

2 誤っている

最判昭 50.11.28（百選 I 24 事件）は、「防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は、防衛の意思を欠く結果、正当防衛のための行為と認めることはできないが、防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、防衛の意思を欠くものではない」としており、また、最判昭 60.9.12 は、「専ら攻撃の意思に出た場合」については防衛の意思が否定されるとする趣旨を示しており、攻撃の意図が防衛の意図を排除し尽くすような極めて例外的な場合に限って防衛の意思が否定される。よって、判例によると、防衛の意思と攻撃の意思が併存する場合、その主従を比較して、前者が優越する場合に限り正当防衛が成立するというわけではない。

3 誤っている

最判昭 44.12.4 は、「やむを得ずにした行為」（36条1項）につき、「急迫不正の侵害に対する反撃行為が、自己または他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること、すなわち反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを意味する」としている。その判断に際しては、一応、武器対等の原則が一応の指針となるが、絶対的な基準とはされていない。最判平元.11.13（百選 I 25 事件）は、素手による侵害に対し、包丁を持ち出して脅迫した事案について、体格・体力で自己を圧倒する相手を威嚇するために用いているにとどまる場合のように「危害を避けるための防御的な行動に終始していた」場合に、相当性を肯定している。よって、判例によると、凶器を持たない相手からの侵害行為に対抗する場合、正当防衛が成立するには、必ずしも凶器を持たずに対抗する必要はない。

4 誤っている

大判昭 8.9.27 は、36条1項にいう「不正」とは、違法であることを意味するとしている。すなわち、不正の侵害というためには、違法であれば足り、それが故意行為であるか過失行為であるかを問わない。よって、侵害が相手方の過失に基づくものであっても、正当防衛が成立する余地がある。したがって、相手方の過失行為に対しても、正当防衛は成立し得る。

5 正しい

最判昭 46.11.16 は、「36条の防衛行為は、防衛の意思をもつてなされることが必要であるが、相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといって、ただちに防衛の意思を欠くものと解すべきではない」とし、また、最判昭 60.9.12 は、「急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、たとえ、同時に侵害者に対し憎悪や怒りの念を抱き攻撃的な意思に出たものであっても、その行為は防衛のための行為に当たると解するのが相当である」としている。したがって、判例によれば、急迫不正の侵害に対して憤激又は逆上して反撃を加えた場合でも、正当防衛は成立し得る。

以上により、正しい記述は1と5であり、したがって、正解は肢1と肢5（順不同）となる。